

0002801-32.2021.8.26.0266

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho

Comarca: Itanhaém

Foro: Foro de Itanhaém

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... praticar, reiteradamente, o crime de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Segundo apurado, os denunciados, associaram de forma estável e contínua para a prática do crime de tráfico de droga e, para tanto, GABRIEL gerenciava o ponto de venda, bem como armazenava entorpecentes na própria residência, juntamente com KATRERINNE, sua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itanhaém

Foro de Itanhaém

1ª Vara

Avenida Rui Barbosa, 867, Itanhaém-SP - cep 11740-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0002801-32.2021.8.26.0266 - lauda

CONCLUSÃO

Aos 07/03/2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Judicial, Exmo. Sr. Dr. PAULO ALEXANDRE RODRIGUES COUTINHO. Eu, _____, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002801-32.2021.8.26.0266

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL NOVAIS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho

VISTOS...

GABRIEL NOVAIS DA SILVA, Rafael Gode Vital e Katherinne Cristina Coutinho, já qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público, valendo-se da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, como incursos nas sanções dos artigos 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos delituosos narrados na introitoal de fls. 02/05, a saber:

"Consta do incluso inquérito policial que, no dia 06 de dezembro de 2020, por volta das 21h, na Rua Cabuçu, município e comarca de Itanhaém, RAFAEL GODE VITAL, qualificado às fls. 09, trazia consigo, para fins de venda e entrega a terceiros, 31 porções de Cannabis sativa L e 66 pequenos tubos plásticos contendo cocaína, drogas que determinam dependência física e psíquica, fazendo-o, porém, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta, também, que, no mesmo dia 06 de dezembro de 2020, por volta das 21h, na Rua Vitória, 128, Magalhães, Itanhaém, GABRIEL NOVAIS DA SILVA e KATRERINNE CRISTINA COUTINHO,

qualificados às fls. 09, agindo em unidade de desígnios, mantinham em depósito, para fins de tráfico, 600 invólucros plásticos contendo cocaína e 774 porções de Cannabis sativa L, fazendo-o, porém, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta, ainda, que, durante um período de tempo não precisamente determinado, mas que perdurou até o dia 06 de dezembro de 2020, neste município de Itanhaém, GABRIEL NOVAIS DA SILVA, KATRERINNE CRISTINA COUTINHO e RAFAEL GODE VITAL, qualificados às fls.09/11, associaram-se entre si e com outros indivíduos ainda não identificados, de forma estável, para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Segundo apurado, os denunciados, associaram de forma estável e contínua para a prática do crime de tráfico de droga e, para tanto, GABRIEL gerenciava o ponto de venda, bem como armazenava entorpecentes na própria residência, juntamente com KATRERINNE, sua convivente, fracionando e embalando-os, bem como abastecendo costumeiramente o ponto de tráfico, mediante rotineira entrega de drogas ao denunciado GABRIEL e a outros indivíduos, que se encarregavam da efetiva venda a usuários, sendo GABRIEL também o responsável por recolher o dinheiro auferido com o comércio ilícito, encaminhando os valores ao “dono da biqueira”, pessoa ainda não completamente identificada, conhecida pelo prenome de CAETANO. Assim, no dia dos fatos, policiais militares observaram o denunciado RAFAEL trazendo consigo uma sacola plástica verde, na avenida Cabuçu, e, diante de sua tentativa de evadir-se prenderam-no em flagrante, seguindo-se a apreensão de 31 porções de Cannabis sativa L e de 66 pequenos tubos plásticos contendo cocaína, bem como de R\$ 30,00, valor produto do tráfico de droga. Seguindo informações do próprio denunciado GABRIEL, os agentes policiais seguiram até à residência do casal de denunciados GABRIEL e KATRERINE, onde, por indicação dessa última, apreenderam, na gaveta de uma cômoda, 600 invólucros plásticos contendo cocaína e 774 porções de Cannabis sativa L, assim como um caderno com anotações próprias da contabilidade de tráfico de droga, uma balança de precisão, papel filme e um aparelho celular, ultimando-se a prisão em flagrante da denunciada, ao tempo em que seu convivente não foi localizado, na ocasião.”

Acompanhou a denúncia o auto de prisão em flagrante, no qual, estando em termos, foram juntados, dentre vários outros documentos, termos de declarações, boletim de ocorrência (fls. 14/16), auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), auto de constatação preliminar de entorpecentes (fl.19) e o relatório lavrado pela polícia judiciária (fls. 68/69). Ulteriormente, foi anexado aos autos o laudo toxicológico (fls. 99/101).

Às fls. 26/27 a Defensoria Pública do Estado de São Paulo requereu a concessão de liberdade provisória aos acusados Rafael e Katherinne. O Parquet manifestou-se às fls. 28/31. Dispensada a audiência de custódia, ex vi do Provimento CSM 2545/2020, as prisões em flagrante foram convertidas em preventivas, com esteio no art. 312 do Código de Processo Penal, por entendê-las necessárias à garantia da ordem pública (fls. 32/33).

À fl. 49 determinou-se a notificação dos acusados, para fins de apresentação da defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06. À fl. 136 determinou-se a citação editalícia do corréu Gabriel. Notificados, os acusados apresentaram resposta a acusação (fls. 147/149 – Rafael e Katherinne, e fls. 186/187 – Gabriel), por intermédio de defensores dativos.

Por estar em termos, foi recebida a denúncia e, não sendo o caso de absolvição sumária, foi designada audiência por plataforma remota (fls. 193/197). Na oportunidade, com esteio no art. 312 do Código de Processo Penal, decretou-se a prisão preventiva de Gabriel. Às fls. 252/254 o feito suspenso em relação ao réu foragido, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal. Tendo em vista o óbito comunicado pelo estabelecimento prisional à fl. 288, fora julgada extinta a punibilidade de Rafael, com fundamento no artigo 107, inciso I, do Código Penal (fl. 293).

Na solenidade, abertos os trabalhos, interrogou-se a corré Ketherinne e determinou-se o desmembramento do feito em relação a Gabriel (fls. 309/311). No presente feito, o mandado de prisão fora cumprido às fls. 353/354 e o acusado apresentou nova resposta à acusação às fls. 370/371. Nova audiência designada às fls. 377/379.

Na data aprazada, ressaltou-se que o réu seria interrogado após a inquirição das testemunhas arroladas, seguindo a mesma sistemática do procedimento comum ordinário, sumário e sumaríssimo. Na sequência, foram inquiridas as testemunhas Alexandre e Rodrigo, arroladas em comum pelas partes, bem como foi interrogado o réu. Em vista da inexistência de diligências complementares, rumou o feito para os debates orais. A acusação, em linhas gerais, propugnou pela procedência parcial da denúncia, ao passo que a defesa requereu a absolvição do réu, sob a égide da anemia de provas.

É o breve relato dos autos (artigo 381, incisos I e II, do Código de Processo Penal). FUNDAMENTO e DECIDO.

Trata-se de ação penal manejada pelo Ministério Público com o fito de obter a condenação do acusado Gabriel Novais da Silva nas sanções dos artigos 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06.

Em relação ao crime previsto no ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006:

Narra a denúncia que no dia 06 de dezembro de 2020, por volta das 21h, na Rua Vitória, 128, Magalhães, Itanhaém, Gabriel Novais da Silva e Katherinne Cristina Coutinho, agindo em unidade de desígnios, mantinham em depósito, para fins de tráfico, 600 invólucros plásticos contendo cocaína e 774 porções de Cannabis sativa L, fazendo-o, porém, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A materialidade dos fatos se enfeixa no auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), no auto de constatação prévia de entorpecentes (fl. 19) e, principalmente, no laudo pericial toxicológico de fls. 99/101, oportunidade em que concluíram os experts tratarem-se as substâncias apreendidas de 215,1g de Cocaína e 1.618,5g de Tetrahydrocannabinol. A autoria da acusada, por seu turno, restou bem delineada por intermédio da prova testemunhal produzida.

O interrogatório do réu realizado na etapa indiciária restou prejudicado, porquanto ausente. Em Juízo, na essência, negou os fatos. Afirmou que já estava separado de Katherine acerca de um ano antes do ocorrido, por haver descoberto uma traição perpetrada por ela. Não soube esclarecer o motivo pelo qual sua cédula de identidade se encontrava no endereço da corré. Negou, outrossim, a propriedade da droga encontrada na residência localizada na rua Vitória, 128, Magalhães, Itanhaém.

Todavia, quando confrontada a versão externada pelo acusado com as demais provas produzidas, desfalece ante sua fragilidade, evidenciando, sobremaneira, tratar-se de um subterfúgio lançado para elidir os rigores da lei penal.

O Policial Militar Alexandre (fl. 08), em seu depoimento externado em solo indiciário, relatou que, na data dos fatos, encontrava-se em serviço na Av. Cabuçu, em ponto já conhecido para venda de drogas. Em um dado momento, visualizou Rafael, que estava com uma sacola verde na mão. Este, ao avistar a viatura, tentou empreender fuga, contudo, fora capturado e abordado. Em revista pessoal, encontrou na sacola R\$ 30,00, 66 eppendorfs de cocaína e 31 porções de maconha, sendo que, ao pesquisá-lo, constatou que este era procurado pela Justiça, tendo em vista Mandado de Prisão nº 0002807.77.2018.8.26.0158.01.01.02.15. Ocorre que, na intenção de não ser preso, Rafael disse que poderia entregar o endereço da casa do gerente da boca, ou seja, do indivíduo de nome Gabriel. Acrescentou ainda que este morava com a

Katherine, sendo que ambos preparavam a droga naquele local, onde sempre retirava os entorpecentes. Quanto ao dinheiro, Gabriel é quem recolhia e depois repassava para um tal de Caetano, o dono da biqueira. Sendo assim, Gabriel tinha a função de preparo e abastecimento da droga e recolha do dinheiro. Diante de tais informações, dirigiu-se à Rua Vitoria nº 128-B, onde foi recebido por Katherine, a qual franqueou sua entrada. Relatou ainda que, ao saber da denúncia, a inculpada confessou dizendo que Gabriel era o gerente da boca e que ela apenas o auxiliava na embalagem da droga, mas que ela não participava da venda. Alinhavou que Katherine indicou uma gaveta da cômoda, onde encontrou 600 pinos de cocaína, 774 porções de maconha, um caderno com a contabilidade, uma balança de precisão e papel filme.

Em Juízo, na presente solenidade, além de reafirmar a mesma narrativa, esclareceu já haver prendido Katherine em outra oportunidade, também por tráfico. Katherine ainda lhe relatou que trabalhava para seu namorado Gabriel, pessoa ausente no ato da prisão. Salientou que Rafael também noticiou receber a droga de Gabriel, sendo que o pagamento se dava em favor de Katherine.

Estes, em linhas gerais, foram os mesmos fatos articulados pelo policial militar Rodrigo, em seu depoimento prestado em solo policial (fl. 11), e também sob o crivo do contraditório. Ainda na presente solenidade, esclareceu o policial que na residência de Katherine a identidade de Gabriel, o que confirmado pelo auto de exibição e apreensão de fl. 17/18.

É cediço que o valor do depoimento policial, inexistindo má-fé, constitui importante elemento de prova, o qual merece confiança, pois realizado após compromisso e sem contradita da parte do réu. Aliás, sobre a validade dos depoimentos dos policiais, relembre-se que:

"o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - 1ª Turma - HC 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU de 11.04.97, pág. 12.189).

Estas são as provas. Diferentemente do que pretendem fazer crer a defesa, entendo assistir razão à acusação na imputação que é ofertada ao acusado. É que a quantidade das drogas encontradas - 215,1g de Cocaína e 1.618,5g de Tetrahydrocannabinol - transparece a finalidade comercial própria do tipo penal. Observe-se que os entorpecentes apreendidos já se encontravam em pequenas porções, adrede preparados para venda.

Veja-se que os militares já detinham a informação de que Gabriel desempenhava a função de gerente do ponto de venda de drogas da Cabuçu, na medida em que, momentos antes, teriam abordado Rafael. Este, como visto, confessou sua incursão no comércio ilícito de drogas, bem como indicou Gabriel como sendo o responsável pelo fracionamento e distribuição dos entorpecentes.

Nesta toada, os agentes estatais rumaram à casa do increpado. Ao chegarem no local, foram recepcionados por Katherine, cônjuge do réu. Esta, ao tomar ciência do ocorrido, confirmou que o esposo era o gerente da boca e indicou a gaveta de uma cômoda. No móvel, os policiais encontraram uma segunda quantidade de entorpecentes, anotações alusivas a contabilidade da traficância, bem como apetrechos para fracionamento da droga espúria.

Logo, todo o contexto da situação não deixa dúvida acerca da conduta ilícita cometida pelo acusado. De resto, não se pode imaginar razões que justifiquem a alegação de estarem os policiais a acusar desconhecidos da prática de um delito, quando isso não ocorreu, unicamente para atender a algum sentimento íntimo sádico de culpar terceiros.

Acrescente-se, outrossim, que a ré Katherine, quando de seu julgamento nos autos n. 1519092-67.2020.8.26.0266 (fls. 313/326), confessou os fatos nos termos da peça incoativa, sendo condenada ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, feito em que já se aperfeiçoou o trânsito em julgado.

O contexto formado, portanto, inculca neste Juízo inexorável certeza de que o réu Gabriel efetivamente era o titular da expressiva quantidade de entorpecentes apreendida. Além de delatado por Rafael, indivíduo que, lamentavelmente, veio a óbito por ocasião da instrução dos autos originários, também foi apontado por sua própria consorte, quando da diligência realizada pela polícia militar. Não por outros motivos permaneceu foragido por considerável interregno. Ademais, pontue-se que, embora tenha negado o relacionamento com Katherine, sua cédula de identidade fora encontrada no endereço em questão, a tornar indubitosa sua participação no delito.

Tais aspectos amoldam-se perfeitamente à narrativa fornecida pelos policiais, sendo certo que, se inverídicas tais informações, não haveria razão para que os agentes estatais se dirigissem ao endereço do casal Gabriel e Katherine, local onde encontrada a expressiva quantidade de entorpecentes, tal qual indicado por Rafael.

Como já destacado, no caso dos autos, diversos são os elementos que apontam o acusado como sendo o autor do crime. Não está em se falar, pois, em meras conjecturas, mas sim fortes indícios e provas circunstanciadas robustas, capazes de formarem o livre convencimento voltado à prolação de uma sentença condenatória. Sendo os indícios fortes e as demais provas robustas, inculca-se a este juízo, portanto, certeza quanto à efetiva prática do delito. Desta forma, de rigor sua condenação em relação ao delito praticado contra a vítima.

A respeito da admissibilidade destes indícios para se fundamentar sentença condenatória, resta pacificado na jurisprudência atual ser possível sua consideração como meio de prova, lastreada no disposto no artigo 239, do Código de Processo Penal, vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS À ENSEJAR UMA CONDENAÇÃO - INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS VEEMENTES - EXEGESE DO ART. 239 DO CPP - VALIDADE COMO MEIO PROBATÓRIO - PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS CIRCUNSTANCIAS ROBUSTAS À ATESTAR A PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NO EVENTO DELITUOSO - RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO: Há autorização legal para sua utilização no artigo 239 do CPP. Isto se deve ao fato de que nem tudo se prova diretamente, pois há crimes camuflados - a grande maioria - que exigem a captação de indícios para a busca da verdade real. Não há, portanto, que se falar em insuficiência de provas quando presentes indícios cabais de autoria, acompanhados de provas circunstanciais robustas. Recurso conhecido, mas desprovido. - (TJES, Apelação nº 46059000011 ES 046059000011).

No mesmo sentido o posicionamento do Supremo Tribunal Federal por ocasião do Habeas Corpus nº 83.348-9/SP:

“Por outro lado, o conceito de “certeza” e “verdade” são inatingíveis, sendo que o processo, num mecanismo dialético, busca aproximar-se o máximo possível do que realmente ocorreu. Se, em face de tudo o que foi produzido e debatido durante o contraditório, o juiz atingir um grau de certeza que lhe dê segurança para

condenar, assim deverá proceder. (...) A perspectiva que disso se extrai, diante da livre persuasão motivada do juiz, é de não se excluir, em abstrato, o valor da prova indiciária”.

A respeito da coautoria no crime de tráfico de drogas, o entendimento jurisprudencial é de que:

“O delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 admite coautoria ou participação, respondendo o agente que de outra forma contribuiu para o fato, ainda que não tenha praticado a conduta descrita no verbo nuclear do tipo. Na hipótese de concurso de pessoas, não se exige que o coautor tenha a posse direta da droga para o reconhecimento do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, bastando demonstração de que contribuiu para a execução da prática criminosa” – (TRF 4ª Região – Apelação criminal: ACR 50008582920134047214/SC, julgamento em 03/06/2014, Sétima Turma).

Neste sentido:

“Admite coautoria ou participação, respondendo o agente que de outra forma contribuiu para o fato, ainda que não tenha praticado a conduta descrita no verbo nuclear do tipo. Mesmo em caso de concurso de pessoas, 'não se exige a posse direta da droga para configuração do tráfico nos casos de co-autoria, bastando o conluio prévio com aquele que transporta, por exemplo' (TRF4, ACR 50048237920124047204, Rel. Luiz Carlos Canalli [Conv.], 7ª T. u., j. 29.10.2013). De fato, se a infração é executada em concurso de pessoas, não a desnatura o fato de o tóxico ter sido apreendido na posse de outro agente, o qual praticou o verbo proibido na normal penal. Outrossim, "a prova da materialidade em relação a um dos acusados aproveita o co-réu, ex vi art. 29 do CP" (STJ. HC 12997, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., u., j. 26.9.2000)”.

Portanto, o conjunto probatório amealhado evidencia a efetiva prática do crime de tráfico de drogas por ambos os acusados. Diga-se de passagem, oportuno lembrar que:

“o crime de tráfico de entorpecentes compreende dezoito ações identificadas pelos diversos verbos ou núcleos do tipo, em face do que tal delito se consuma com a prática de qualquer delas, eis que delito de ação múltipla ou misto alternativo” (STJ; HC 27704/MS; Sexta Turma; Min. Rel. Hamilton Carvalhido; J. em 09/05/2006).

E ainda:

“considera-se consumado o tráfico quando evidenciada o estado de flagrância em quaisquer de seus núcleos, ou seja, no momento da importação ou exportação, do depósito ou do transporte, de trazer consigo ou da guarda do entorpecente.” (STJ; HC 34374/MS, Min. Gilson Dipp; Quinta Turma; DJ 01/07/2004).

Assim, dúvidas não pairam de que o réu encontra-se incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Em relação ao crime de ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO:

Narra a denúncia que, durante um período de tempo não precisamente determinado, mas que perdurou até o dia 06 de dezembro de 2020, neste município de Itanhaém, Gabriel, Katrerinne e Rafael, associaram-se entre si e com outros indivíduos ainda não identificados, de forma estável, para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

De antemão, sobre o ônus da prova, entendo oportuna a ponderação de algumas ressalvas que balizarão a conclusão alcançada nesta sentença, ajustando sua distribuição, no âmbito penal, em conformidade com o filtro constitucional.

E, para tanto, soa adequado rememorar, com espeque na lição de Aury Lopes Júnior, que não se incumbem às partes obrigações, mas sim cargas processuais, “entendidas como a realização de atos com a finalidade de prevenir um prejuízo processual e, conseqüentemente, uma sentença desfavorável. Tais atos se traduzem, essencialmente, na prova de suas afirmações” (Direito processual penal e sua conformidade constitucional. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2009, pag. 45).

Ocorre que, no processo penal, a carga da prova está inteiramente nas mãos do acusador, “não só porque a primeira afirmação é feita por ele na peça acusatória (denúncia ou queixa), mas também porque o réu está protegido pela presunção de inocência” (ob. cit.) (Grifei).

Vale dizer, em âmbito penal, considerando a relevância e indisponibilidade da natureza da matéria discutida – liberdade do indivíduo – não existe uma distribuição na produção da prova, pois esta se encontra exclusivamente nas mãos do Ministério Público.

Ainda segundo o escólio do referido professor, “o que sim podemos conceber, indo além da noção inicial de situação jurídica, é uma assunção de riscos. Significa dizer que à luz da epistemologia da incerteza que marca a atividade processual e o fato de a sentença ser um ato de crença, de fé (como explicaremos a seu tempo), a não produção de elementos de convicção para o julgamento favorável ao seu interesse faz com que o réu acabe potencializando o risco de uma sentença desfavorável. Não há uma carga para a defesa, mas sim um risco. Logo, coexistem as noções de carga para o acusador e risco para a defesa.” (Grifo no original) (ob. cit.).

Em outras palavras, “carga é um conceito vinculado à noção de unilateralidade, logo, não passível de distribuição, mas sim de atribuição. No processo penal, a atribuição da carga probatória está nas mãos do acusador, não havendo carga para a defesa e tampouco possibilidade de o juiz auxiliar o MP a liberar-se dela (recusa ao ativismo judicial)” (ob. cit.).

Pode-se falar, portanto, que a defesa assume riscos pela perda de uma chance:

“Assim, quando facultado ao réu fazer prova de determinado fato por ele alegado e não há o aproveitamento dessa chance, assume a defesa o risco inerente à perda de uma chance, logo, assunção do risco de uma sentença desfavorável. Exemplo típico é o exercício do direito de silêncio, calcado no nemo tenetur se detegere. Não gera um prejuízo processual, pois não existe uma carga. Contudo, potencializa o risco de uma sentença condenatória. Isso é inegável”(ob. cit.) (Grifei).

A conclusão a que se alcança, portanto, é a de que “não há uma carga para a defesa exatamente porque não se lhe atribui um prejuízo imediato e tampouco possui ela um dever de liberação. A questão desloca-se para a dimensão da assunção do risco pela perda de uma chance de obter a captura psíquica do juiz. O réu que cala assume o risco decorrente da perda da chance de obter o convencimento do juiz da veracidade” (ob. cit.) (Grifei).

Em suma, a necessidade de produção da prova para amparar a condenação do réu repousa unicamente nas mãos da acusação, não havendo que se falar em distribuição de cargas processuais.

Assentadas essas premissas, passo ao crime perquirido.

Ao acusado imputa-se o crime do art. 35, caput, da Lei 11.343/2006, tal como asseverado no preâmbulo da presente sentença, a saber:

“Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no art. 36 desta Lei."

Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci, "exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo art. 14 da Lei n. 6.368/76) é fundamental que os ajustes se reúnam com o propósito de manter uma meta comum. Não existe a forma culposa (Leis penais e processuais penais comentadas. São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 1. ed., 2006, p. 785).

E mais, "consoante jurisprudência pacificada do STF e do STJ, o art. 35 configura-se pela efetiva associação, com idéia de estabilidade e permanência. Deve haver 'animus' associativo e não mero concurso eventual de pessoas. Assim, o crime de associação não depende da apreensão da droga; sua comprovação pode ser feita nos mesmos moldes da quadrilha (art. 288 do Código Penal). Trata-se de crime formal, que se consuma com a demonstração do desígnio de convergência de vontades para traficar droga." (Gilberto Thums e Vilmar Pacheco in Nova Lei de Drogas - Crimes, Investigação e Processo, ed. Verbo Jurídico, 2007, págs. 92/93).

Exige-se, portanto, a demonstração de vínculo estável entre os agentes, voltado à prática do tráfico de drogas.

No presente caso, todavia, as provas carreadas são insuficientes a uma condenação. De todo oportuno pontuar que, embora tenham apreendido entorpecentes na residência do réu (215,1g de Cocaína e 1.618,5g de Tetrahydrocannabinol), com a máxima vênua ao órgão acusador, não compartilho do entendimento de que a hipótese dos autos não deixa dúvidas sobre o envolvimento do incriminado no comércio de drogas.

Isto porque no decurso do feito, além dos depoimentos dos policiais militares, nenhuma outra prova a este respeito foi produzida a fim de comprovar o dolo de se associar com estabilidade e permanência. É claro que não se está a dizer que faltaram os policiais com a verdade frente a este Juízo. Todavia, a conclusão a que alcanço, é a de que a prova produzida pela acusação se vislumbra demasiadamente frágil.

O Direito Penal, vale lembrar não opera com meras conjecturas, suposições ou ilações e se a prova produzida pela acusação não foi suficiente para confirmar os fatos descritos na denúncia, a absolvição da parte acusada é medida que se impõe, em atenção ao princípio do in dubio pro reo.

Helena Cláudio Fragoso (Jurisprudência Criminal, Editora Forense, 4ª edição, página 506), observava:

"Não é possível fundamentar sentença condenatória que não conduz à certeza. Esse é um dos princípios basilares do processo penal em todos os países democráticos. A condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno da existência de certa realidade".

Acerca dessa matéria:

"O Direito Penal não opera com conjecturas. Sem a certeza total da autoria e da culpabilidade não pode o juiz criminal proferir condenação" (Apelação 170.407, TACRIM-SP).

"Aplicação do princípio in dubio pro reo. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para a condenação criminal exigente de

certeza plena. Como afirmou Carara, 'a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata com como a matemática' Deram parcial provimento Unânime" (RJTJESGS 17/136).

Em resumo, a absolvição do acusado em relação ao crime previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, é medida que se impõe, com esteio no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

DOSIMETRIA:

Em relação ao crime de TRÁFICO DE ENTORPECENTES:

A culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta da acusada, deve ser considerada normal.

Não obstante reincidente (fl. 55), o acusado não é possuidor de antecedentes criminais. E isso porque, não havendo condenação definitiva (fora do caso de reincidência), tal aspecto não poderá ser valorado em seu desfavor, por respeito ao princípio da presunção de inocência, resguardado em âmbito constitucional. Vale dizer,

"(...) inquéritos policiais ou ações penais em andamento, inclusive, sentença condenatória sem o trânsito em julgado, não podem, em razão do princípio constitucional do estado presumido de inocência, ser considerados para agravar a pena-base do condenado"(STJ; HC 92665/RJ; Min. Laurita Vaz; 5ª Turma; J. em 13/08/09).

Nesse sentido, aliás, é a Súmula 444 do STJ.

Sobre a conduta social e a personalidade do acusado não foram amealhados elementos suficientes nos autos. Os motivos são próprios à espécie.

As circunstâncias, no entanto, devem ser consideradas gravosas tendo em vista a quantidade dos entorpecentes apreendidos (942 porções de cocaína - 215,1g e 1.632 porções de maconha - 1.618,5g) e as circunstâncias que envolveram o fato. Vale a consideração, também, que o montante de entorpecente apreendido se traduz no mercado ilícito em expressiva cifra, pelo que, fica exasperada a pena em 1/6.

Nesse sentido:

"(...) na avaliação das circunstâncias legais para fixação da pena, em se tratando de tráfico de entorpecentes, devem influir decisivamente a espécie e a quantidade de droga. O tipo de entorpecente é dado que indica o grau de nocividade para a saúde pública, correlato ao indicador das consequências do crime; a quantidade, quase sempre, aponta para o grau de envolvimento do infrator com o odioso comércio, indicando a medida de sua personalidade perigosa e voltada para a prática criminosa" (STJ, Rel. José Arnaldo da Fonseca, HC 18940/RJ).

As consequências devem ser consideradas normais. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

Diante destas circunstâncias judiciais, aplico a pena-base ao réu em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do artigo 43 da Lei n. 11.343/06.

Presente a agravante da reincidência (vide certidão de fl. 104 - condenação pelo crime de tráfico, processo nº 0000445-11.2014.8.26.0266, 3ª Vara da Comarca de Itanhaém). A este respeito, anoto que, se uma exasperação da reprimenda é de rigor,

estando presente a agravante do artigo 61, I, do Código Penal, em se tratando de um caso de reincidência específica, a resposta punitiva do Estado deve se fazer sentir com maior severidade, porquanto evidenciados o fracasso das penas anteriormente impostas, sobretudo em sua finalidade preventiva específica, e a recalcitância do réu em amoldar sua conduta a padrões dignos de conduta. Assim, agravo a pena em 1/4, por se tratar de reincidência específica.

"(...) O Código Penal não especifica limites mínimo e máximo de exasperação ou redução de pena a serem aplicados em razão da incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes genéricas, cabendo ao magistrado, de maneira prudente, com observância ao livre convencimento motivado, fixar o patamar que entender necessário e suficiente à espécie, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tratando-se, assim, de discricionariedade vinculada à devida fundamentação.2. In casu, o acréscimo da pena pela reincidência se deu em 1/4, fração de aumento que não se mostra desarrazoada, tendo em vista escorreita valoração dada diante da reincidência específica do paciente. Não há falar, pois em constrangimento ilegal. (...)"(STJ-HC: 397898 RJ-2017/0097255-9. Relator: Ministra MARIATHEREZA DE ASSIS MOURA. DJ: 23/05/2017, T6. DP: DJe30/05/2017).

Presente também a agravante do art. 61, ii, "j", agravo a pena em 1/6. Anote-se que, conforme bem enfatizado pelo Exmo Des. Edison Brandão, nos autos do julgamento da apelação n. 1509419-67.2020.8.26.0228, "de se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência." Ausentes quaisquer atenuantes.

Ausentes quaisquer causas de aumento e de diminuição, inclusive a prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, face à reincidência do acusado.

Inexistindo outras causas de modificação da pena, torno-a, destarte, em definitivo, em 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 825 (oitocentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 43 da Lei n. 11.343/06.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, ex vi do art. 2º, §1º, da Lei n. 8.072/90, e dada à reincidência operada.

A possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por outras restritivas de direito há de ser analisada sob o prisma do art. 44 do Código Penal. Conquanto expressa a vedação acerca da aplicação do instituto aos casos de tráfico, tal qual se depreende dos artigos 33, §4º, e artigo 44, ambos da Lei n. 11.343/06, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Habeas Corpus n. 97256, publicado em 16/12/2010, cujo relator foi o Min. Ayres Brito, em controle difuso de constitucionalidade, concedeu a segurança pretendida para:

"remover o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão análoga 'vedada a conversão em penas restritivas de direitos', constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal." E isso por se entender que "o processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao delinquente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo. Implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva pela prevalência do razoável sobre o racional; ditada pelo permanente esforço do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça

material."

Ademais, em 15/02/2012, o Senado Federal, valendo-se da prerrogativa que lhe é dada pelo art. 52, inc. X, da Constituição Federal, editou a Resolução n. 5, suspendendo a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Ainda que a Resolução editada pelo Senado Federal tenha se limitado a suspender a restrição existente somente no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, forçosa é a extensão de sua leitura também para a redação dada ao art. 44 do mesmo diploma, quando veda o mesmo benefício. É que o precedente jurisprudencial que motivou a edição da Resolução referida entendeu por inconstitucional tanto a vedação contida no art. §4º do art. 33 como também a do artigo 44, ambos da Lei n. 11.343/06.

Todavia, mesmo que assentadas tais premissas, as circunstâncias do caso indicam não ser recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou, ainda, a suspensão condicional de sua execução. Como já positivado, além de a pena aplicada afrontar o requisito legal, o acusado é reincidente.

DIANTE DO EXPOSTO:

a) JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA para ABSOLVER o acusado GABRIEL NOVAIS DA SILVA, já devidamente qualificado no preâmbulo destes autos, das imputações previstas no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com base no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

b) JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA e, em consequência, CONDENO a acusada GABRIEL NOVAIS DA SILVA, já qualificado, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 08 (OITO) ANOS, 01 (UM) MÊS E 05 (CINCO) DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 825 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO) DIAS-MULTA, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 43 da Lei n. 11.343/06. Isto por considerá-lo incurso nas sanções dos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Deixo de condenar o réu em custas processuais, dada à hipossuficiência financeira denotada.

Por estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, ante os fundamentos elencados na decisão de fls. 193/197, não reconheço a acusada o direito de recorrer em liberdade, recomendando-se o ergástulo em que se encontra até o trânsito em julgado (art. 387, §1º, c/c art. 312, ambos do CPP).

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do CPP, por entender incompatível tal estipêndio com o crime apurado, dada a natureza difusa das vítimas.

Decreto a perda em favor de entidade beneficente cadastrada neste Juízo do dinheiro apreendido (vide fl. 146, R\$ 30,00 reais).

Transitada em julgado, tome o cartório as seguintes providências:

1. Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;
2. Lance-se o nome do acusado no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal;
3. Extraia-se a guia de execução definitiva e encaminhe-se-a ao Juízo da Execução, conforme art. 105 da 7.210/84;
4. Desde logo, não havendo interesse em recorrer, sai a parte acusada intimada para pagamento da pena de multa, bem como da taxa judiciária, se houver, no prazo de 10

dias. Recolhida, comunique-se a respeito ao Juízo da Execução; decorrido in albis o prazo ou infrutífera a intimação, nos termos do art. 480-A das NSCGJ, extraia a serventia certidão da sentença, abrindo-se vista ao Ministério Público (ato ordinatório – cód. 505790). Havendo interposição recursal, i-se-a quando do trânsito em julgado.

Publique-se. I-se.

Itanhaém, 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA